

0001677-35.2016.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001677-35.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001677-35.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Brendo Moura Domingues e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

BRENDO MOURA DOMINGUES e ROBERSON MATOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta que, no dia 30 de setembro de 2016, por volta das 17h30, na Viela Paz de Deus, s/nº, Jardim Santa Maria, nesta cidade e Comarca, BRENDO foi detido enquanto trazia consigo, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de "maconha", contendo o total de 29,95 gramas (item E/5 - lacre nº 0100852), 15 (quinze) tubos/"pinos" contendo o total de 25,67 gramas de cocaína (item F/6 - lacre nº 0100853), e 30 (trinta) invólucros plásticos transparentes contendo 9,63 gramas de cocaína na forma de "crack" (item G/7 - lacre nº 0100854), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que no dia 30 de setembro de 2016, por volta das 17h30, na Viela Paz de Deus, s/nº, Jardim Santa Maria, nesta cidade e comarca de Osasco, ROBERSON guardava, para fins de tráfico, 4.028 (quatro mil e vinte e oito) invólucros plásticos contendo o total de 808,21 gramas de cocaína na forma de "crack" (item A/1 - lacre nº 0100848), 780 (setecentos e oitenta) porções contendo o total de

1.602 gramas de “maconha” (item B/2 – lacre nº 0100849) e 03 (três) “tijolos” contendo o total de 3.553 gramas de “maconha” (item C/3 – lacre nº 0100850), 5.934 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro) “pinos”/tubos plásticos contendo 3.037 gramas de cocaína (item D/4 – lacre nº 0100851), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, BRENDÓ MOURA DOMINGUES e ROBERSON MATOS DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

Réus notificados (fls. 349 e 383). Defesas preliminares apresentadas (fls. 280/287 e 293/296)

Denúncia recebida em 05 de dezembro de 2016 (fls. 318).

Réus citados (fls. 414). Respostas apresentadas (fls. 442 e 447).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha comum. Ao final, os réus foram interrogados.

Nas razões finais o Ministério Público requereu preliminarmente a inclusão dos fatos relativos à associação, em consonância com a capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia. No mérito, pleiteou a procedência parcial da ação, condenando-se os réus Brendo e Roberson como incursos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e absolvendo-os da prática do delito previsto no artigo 35 do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 572/587).

A defesa de Brendo pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu recurso em liberdade (fls. 593/609).

A defesa de Roberson também insistiu na absolvição do réu, por ausência de autoria e de provas. De forma subsidiária requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor máximo previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime aberto, com detração do período de prisão cautelar, substituição por penas alternativas, recurso em liberdade e justiça gratuita (fls. 611/621).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, acolho excepcionalmente a preliminar arguida pelo Ministério Público às fls. 574.

No mérito, a ação procede parcialmente. As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

O Policial Willian narrou o flagrante com detalhes. Disse que realizaram uma incursão a pé na “Favela do Limite” e, ao adentrem na comunidade, quatro indivíduos correram. Contou que, durante a fuga, Brendo dispensou uma pochete contendo aproximadamente 20 porções de maconha, 15 de crack e de cocaína, além de um aparelho celular. Disse que Brendo tentou negociar a prisão aduzindo que levaria os policiais até o centro de distribuição de drogas, que ficava no centro da comunidade. Chegando ao local (um cômodo precário com apenas um sofá), se depararam com Roberson, que confirmou que guardava e distribuía entorpecentes. No cômodo encontraram aproximadamente catorze quilos de drogas já fracionadas e com a

discriminação do local em que seriam distribuídas. Os entorpecentes estavam dentro de mochilas em ripas de madeira existentes na parede. Também localizaram três tijolos de maconha, diversos rádios HT e caderno de anotações. Roberson não tinha passagem por tráfico, apenas por roubo, e contou aos policiais que recebia mil reais por semana para cuidar das drogas no local. O policial afirmou que se Brendo não tivesse fornecido as coordenadas, não chegariam no ponto de armazenamento. Esclareceu que as drogas encontradas com Brendo tinham embalagens semelhantes àquelas localizadas no barraco.

Quando do interrogatório, os réus apresentaram versões próprias para os fatos.

O réu Roberson disse que estava em frente da casa da irmã e foi abordado pelos policiais, que lhe perguntaram se possuía passagem e já o levaram. Afirmou conhecer o corréu de vista e que nada sabe sobre as drogas descritas na denúncia. Mencionou ainda que foi levado para um local, do qual viu os policiais carregando uma bolsa com droga. Negou qualquer envolvimento com tráfico de entorpecentes, mencionando que há muitos anos cumpriu pena por roubo e depois que saiu da cadeia, retomou sua vida, sobremaneira quando se tornou pai e não teve mais nenhum problema com a justiça. Mora em casa própria e possui trabalho.

O corréu Brendo alegou, da mesma forma, que foi acusado em razão de seus antecedentes. Disse que estava em frente à sua casa e foi detido, perguntaram se possuía passagens e foi levado para a viatura. Negou qualquer envolvimento com os fatos, informando que conhece o corréu de vista.

Todavia, as versões restaram isoladas nos autos. A defesa não apresentou provas que amparassem as alegações dos acusados ou mitigassem a prova acusatória.

A prova oral é firme e harmônica com os demais elementos de convicção. As circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias e a dinâmica dos fatos restou devidamente comprovada.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elementos de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre nos autos. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e fotografias, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico. A autoria também restou incontestada. Sem lastro, portanto, a alegada insuficiência probatória.

Por outro lado, assiste razão às partes quanto à improcedência em relação no artigo 35 da Lei de Drogas, porquanto não restou comprovado nos autos a estabilidade e permanência que o tipo penal exige.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO DE

AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada para fins de configuração do crime descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/76. Absolvição que não demandou o reexame de provas, mas apenas sua reavaliação. 2. Sendo o Acusado reincidente - o que afasta o requisito da primariedade -, mostra-se incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. 3. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014)

Assim, considerando que as provas são insuficientes para demonstrar o animus associativo de forma estável, duradoura e organizada entre os acusados, com a finalidade de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, de rigor o desfecho absolutório.

Passo à fixação das penas:

- Réu Brendo Moura Domingues

O réu não ostenta antecedentes. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes atenuantes e agravantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a primariedade, bem como a quantidade de dinheiro e droga apreendidos na posse do acusado Brendo, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A míngua de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena.

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts.2º e 60, p.4, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente

seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos , que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o Direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

- Réu Roberson Matos Dos Santos

O acusado não ostenta antecedentes criminais. Verifica-se que a condenação apresentada às fls. 539 transitou em julgado em 2002 e a extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena se deu em 2008, tendo em muito ultrapassado o prazo depurador de cinco anos Sebastião Reis. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes atenuantes e agravantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a primariedade, não havendo prova de associação criminosa ou reiteração da conduta, mas fazendo o cotejo a quantidade de dinheiro e drogas apreendidos com o réu Roberson, diminuo em 1/3 (um terço) a sanção penal.

A minguia de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena, torno como pena definitiva 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial semiaberto, fazendo o cotejo entre a quantidade de drogas apreendida, o montante da sanção e a primariedade.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

CONDENAR BRENDÓ MOURA DOMINGUES, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06;

CONDENAR ROBERSON MATOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (ANOS) E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime semiaberto, e ao pagamento de 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06;

ABSOLVER BRENDÓ MOURA DOMINGUES e ROBERSON MATOS DOS SANTOS, qualificados nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos

do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Considerando o montante da pena e o regime fixado, defiro recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos. Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Osasco, 24 de março de 2022.